

1507301-63.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... e natureza da droga utilizados no tráfico podem ser considerados durante a fixação da pena base. Nesse sentido

"Tráfico - Suficiência probatória - Condenação mantida. 2. Pena-base -

Reprovabilidade exacerbada - Necessário aumento das básicas pela grande quantidade e diversidade das drogas, consoante art. 42, Lei 11.343/06. 3. Agravantes -

Agravante do art. 61, II, "j", do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507301-63.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507301-63.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2250832/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 20250582 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2548/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2250832 - DEL.POL.SALTO, 2548/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VANDI CLEITON GODOY DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu VANDICLEITON GODOY DE SOUSA, como incurso no art. 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. R, porque, em tese, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 20h39min, na Rua Visconde de Cairú, nº 63, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 18 (dezoito) porções de "maconha", com peso aproximado de 33,5g (trinta e três gramas e cinco decigramas); b) 20 (vinte) porções de "cocaína", com peso aproximado de 30,82g (trinta gramas e oitenta e dois centigramas); e c) 36

(trinta e seis) porções de crack, com peso aproximado de 5,74g (cinco gramas e setenta e quatro centigramas), prontas para a comercialização, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 18 de outubro de 2021 (fls. 85-89).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls.130-134).

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2021 (fl.138-139).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.02-04), auto de exibição e apreensão (fl.09), auto de constatação preliminar (fls.10.) e laudo de exame químico toxicológico (fls.96-99), laudo em aparelho celular apreendido (fls. 100-129), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais, Antônio Alessandro Frois e Denis Fernando Froes, testemunhas comuns, foram uníssonos ao relatar que durante patrulhamento pelo local, numa viela, a equipe avistou um rapaz com uma sacolinha branca na mão direita e assim que percebeu a aproximação, jogou a sacola no chão e fugiu. A equipe seguiu em perseguição, o rapaz caiu por duas vezes. Abordado, a equipe encontrou R\$ 70,00, bem como um celular que ele levava em suas mãos. A equipe retornou e ao apanhar a sacola, verificou que em seu interior havia 20 microtubos de cocaína, 18 porções de maconha e 36 porções de crack. Por conta da queda o indiciado sofreu escoriações, contudo, se recusou em passar por atendimento médico. Questionado, permaneceu em silêncio.

O réu, interrogado judicialmente, disse que foi de Uber até o local para comprar drogas para o seu consumo. No local, encontrou um gordinho que ia lhe vender a droga, os guardas chegaram, todos correram. Não conhece o gordinho. Não sabe quem jogou a sacola com drogas no chão.

Com efeito, os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu trazia consigo a droga e após aproximação dos agentes de segurança, fugiu e dispensou uma sacola com a droga no chão, sendo perseguido e o entorpecente localizado pelos policiais embalados e prontos para comercialização.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, não possuem, a priori, motivo algum para falsamente incriminar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

E mais, inexiste dispositivo que os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizerem a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos, pelo contrário, sendo eles investidos em cargo público, o ordenamento jurídico lhes confere presunção de veracidade em suas declarações relacionadas ao exercício de sua função, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência:

"Os agentes públicos não se encontram impedidos de depor sobre atos de ofício nos

processos em que tenham atuado na fase investigatória, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando corroborados por outros elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal. A respeito ensina Guilherme de Souza Nucci: "[...]preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho." A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que "é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (...) Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ - HC: 618963 MS 2020/0269911-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 02/12/2020)

Em que pese a negativa de autoria e alegação de que haveria um terceiro no local, vulgo "gordinho", certo é que as circunstâncias da prisão, a quantidade e variedade de drogas e valor em dinheiro apreendidos denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos, são suficientes a embasar o decreto condenatório. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, esclarece Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o alibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

Antes de iniciar a fixação da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso VLVI, da Constituição Federal, se fazem necessários alguns esclarecimentos acerca dos critérios doutrinários e jurisprudenciais adotados por este julgador durante a dosimetria.

Pela necessidade de observância dos vetores indicados no art. 42 da Lei 11.343/2006 como preponderantes sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade e natureza da droga utilizados no tráfico podem ser considerados durante a fixação da pena base. Nesse sentido

"Tráfico - Suficiência probatória - Condenação mantida. 2. Pena-base - Reprovabilidade exacerbada - Necessário aumento das básicas pela grande quantidade e diversidade das drogas, consoante art. 42, Lei 11.343/06. 3. Agravantes - Agravante do art. 61, II, "j", do CP - Afastamento - Crime sem qualquer relação com a situação de calamidade pública - Confissão - Compensação integral com a reincidência - Repercussão obrigatória da confissão na dosimetria, mormente porque considerada para a condenação - Súmula 545 do STJ - Preponderância da atenuante, por revelar a personalidade do agente. 4. Causas de diminuição - Reincidência - Presente a agravante, inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 5. Regime inicial - Fechado obrigatório, pelo patamar da pena corporal e pela recidiva, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP. 6. Penas restritivas de direitos - Inviável a substituição, pelo patamar da pena corporal e pela recidiva, conforme art. 44, I e II, do CP. 7. Não configuração de "bis in idem" na repercussão negativa da reincidência em diversas etapas da individualização da reprimenda - Precedente do STF com repercussão geral. (TJSP; Apelação Criminal 1517199-58.2020.8.26.0228; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021).

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para

praticar o delito. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“O contexto de calamidade pública, ainda que decretado pelo Poder Público, não é apto à caracterização da agravante, no caso presente, a não ser que, v. g., se estivesse em cenário particularizado, como a falsificação de uma vacina ou o descumprimento de medida sanitária preventiva.” (Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047, Relato: Guilherme de Souza Nucci.)

Essa é a maciça posição do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 8 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 9 QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Acerca da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I do Código Penal, de acordo com ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci in Código Penal Comentado (2017; p.311) tem-se: a) reincidência real: quando o agente comete novo delito depois de já ter efetivamente cumprido pena por crime anterior; b) reincidência ficta: quando o autor comete novo crime depois de ter sido condenado, mas ainda sem cumprir pena. Ainda, dispõe o art. 64, I, do CP que “não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos. Leva-se em conta a data em que a pena foi efetivamente extinta, pouco importando o dia em que foi proferida decisão judicial declaratória de extinção de punibilidade. Logo, no caso em tela, não transcorreu o prazo depurador, contado a partir do fim da execução da pena atinente à condenação definitiva por crime anterior constante do histórico criminal do acusado (certidão de objeto e pé fls. 153-154), configurada está a agravante da reincidência.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, são normais à espécie, sem antecedentes a considerar, as circunstâncias e consequências do crime, podem ser valorados negativamente, considerada a quantidade e sobretudo a diversidade de drogas apreendidas (cocaína, maconha e crack), razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes atenuantes, presente a agravante da reincidência (vide fl. 153-154 - processo 0007128-26.2015.8.26.0526), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 6 anos e 06 meses e 22 dias de reclusão e 583 dias-multa.

Ausentes causa de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de em 6 anos e 06

meses e 22 dias de reclusão e 583 dias-multa, no mínimo legal. Diante da reincidência específica e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial será o fechado, conforme artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu VANDI CLEITON GODOY DE SOUSA à pena de 6 (seis) anos e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Também levando em consideração que o réu é reincidente específico, respondeu ao processo preso, há perigo concreto de reiteração delitiva, razão pela qual nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Comunique-se, desde logo, a penitenciária em que se encontra recolhido ou, se necessário, expeça-se mandado de prisão.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP à advogada dativa, para retirada exclusivamente pela internet.

Publique-se e intime(m)-se

Salto, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA